

1503432-62.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Concessão do redutor na fração de metade. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503432-62.2021.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 19 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr.

FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Nathalie Cristina Cardoso, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503432-62.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2282502/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 20857889 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1537/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2282502 - 03º D.P. SANTOS, 1537/21/010 - 03º D.P. SANTOS, 2282502/2021 - 3º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEL ALBERTO FERREIRA e outro

Justiça Gratuita

Vistos.

ELIEL ALBERTO FERREIRA e MOISÉS DA SILVA FLORÊNCIO, qualificado nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código

Penal, porque, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 02h40min, na Avenida Almirante Cochrane, 341 (Pátio de Sucatas da CODESP), bairro Embaré, nesta cidade e Comarca de Santos, em concurso entre si, teriam subtraído para proveito comum 10 (dez) metros de fios condutores de energia avaliados em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertencentes a CODESP.

Os acusados foram presos em flagrante (págs. 01/18).

Auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 09/11).

Folhas de Antecedentes Criminais (págs. 19/31).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 41/44).

Recebida a denúncia em 20 de outubro de 2021 (pág. 65).

Laudo Pericial (págs. 66/69 e 168/175).

Os réus foram citados (págs. 87 e 90) e apresentaram resposta à acusação (págs. 94/95).

A prisão preventiva dos réus foi revogada, sendo a eles concedida a liberdade provisória (págs. 101/102). Não sendo caso de absolvição sumária, seguiu-se à instrução.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu ELIEL. O réu MOISÉS, citado e intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia, conforme mídia e termo nos autos (págs. 230/231).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em relação ao réu Eliel.

A Defesa, em memoriais, postulou a absolvição dos réus e, subsidiariamente, seja o delito desclassificado para a forma tentada. Sustentando que os réus são primários, requer a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com recurso em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de furto noturno qualificado, que vem assim previsto:

Furto

“Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§1º- a pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

Furto qualificado

§ 4.º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido:

I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III – com emprego de chave falsa;

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.”

A pretensão punitiva é procedente.

Consigno, inicialmente, que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 09/11), pelos laudos periciais (págs. 66/69 e 168/175), além da prova oral produzida.

Outrossim, a autoria é certa a ensejar um decreto condenatório em relação a ambos os réus, senão vejamos.

A testemunha Fábio, em Juízo, disse ser guarda portuário e que foram acionados através do monitoramento da guarda que avistou os indivíduos dentro do pátio e no

momento em que a guarnição apareceu eles já tinham pulado pra fora do pátio e estavam na viela lateral com a res furtiva em fuga. Foram abordados, não esboçaram reação e confessaram de imediato. Tudo estava sendo filmado. Foram detidos e encaminhados para a autoridade competente. Fez o reconhecimento do indivíduo número 3 como sendo Eliel. Questionado se reconhecia mais algum deles, disse que não consegue recordar da face dos demais nesse momento, visto que estão barbeados e limpos.

A testemunha Gilberto, guarda portuário, confirmou em Juízo ter abordado os acusados juntamente com Fábio. Viram pelo sistema de monitoramento e foram até o local abordá-los. Os acusados portavam uma mochila onde estavam os fios e um material de alumínio que parecia um pedaço de escada que utilizaram para sair do armazém. Confessaram informalmente o furto. Questionado se alguma das pessoas apresentadas participou do delito, disse que não pode afirmar, não se lembra. A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes:

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293). No mesmo sentido:

“A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral”. (RJTACRIM 48/228).

No mesmo sentido JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297, 208/273 e RT 530/272. Ainda:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Concessão do redutor na fração de metade. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu

primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e outra de multa. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001618-51.2017.8.26.0594; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03 - Sentença condenatória - Recurso defensivo - Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra dos policiais militares - Validade - Precedentes - Réu encontrado na posse da arma de fogo - Condenação mantida - Dosimetria penal - Inobservância do sistema vicariante - Readequação - Necessidade - Reconhecimento da atenuante da confissão - Atenuante da menoridade relativa não restou caracterizada, uma vez que o réu já possuía vinte e um anos na data do fato - Substituição por restritivas de direito - Impeditivo legal - Regime prisional inicial semiaberto - Adequado à espécie - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000420-09.2015.8.26.0542; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)

A corroborar, o réu Eliel Alberto Ferreira confessou o delito em solo policial (pág. 12) e em Juízo. Interrogado, disse que Moisés o levou para lá, pularam o muro, cortaram os fios, pularam de volta e foram pegos. Aliás, em relação à importância da confissão, realizada espontaneamente no presente processo, apropriada a lição de Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 10 ed., Saraiva, p. 290):

"A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde que corroborados por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais"

Com relação ao réu Moisés, embora em solo policial tenha se mantido silente (pág. 13), ele não compareceu à audiência de instrução, impossibilitando eventual reconhecimento e dando causa à sua revelia.

Deveras, diferentemente do sustentado pela Defesa, a testemunha Fábio, ouvida em Juízo, disse não reconhecer os demais indivíduos a ela apresentados na audiência, entre os quais não se incluía o réu Moisés, o que não é suficiente para afirmar que seria incapaz de reconhecê-lo, caso estivesse presente para a realização do reconhecimento.

Igual conclusão se aplica à testemunha Gilberto, pois, embora não tenha se recordado da fisionomia do acusado Eliel, não se pode prever que não se recordaria do acusado Moisés, caso este estivesse presente no momento do reconhecimento. Mesmo que assim não fosse, importa salientar que os réus foram presos em flagrante, pois detidos com a res furtivae logo em seguida à subtração, fato que, segundo RAFAEL MAGALHÃES, apud TOURINHO FILHO "é a certeza visual do crime".

A expressão também é usada na doutrina clássica por TOSTES MALTA, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com HÉLIO TORNAGHI, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49), razões por que não há que se falar em receptação.

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido: "PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento: 59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente." (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205).

Ademais, “a apreensão da 'res furtiva' em poder do acusado, que não o justifica razoavelmente, desterra eventual escrúpulo acerca de sua culpabilidade e autoriza-lhe sua condenação” (TACRIM-SP - AP. - Rel. Carlos Biasotti - j. 05/03/1998 - RJTACRIM 38/173).

E, justamente neste sentido, também acertada a jurisprudência, que já cogita da inversão do ônus da prova no processo crime em relação aos fatos desconstitutivos da pretensão punitiva estatal, por ser tal prova facilitada ao réu e, na maioria das vezes, impossível ao órgão acusador, na esteira da clássica doutrina da inviabilidade de produção da prova negativa.

Por isso, encontrada a res furtiva em poder dos acusados (págs. 09/11), como já dito, deveriam ter eles apresentado justificativa plausível para a respectiva posse, o que não foi feito.

Portanto, diferentemente do sustentado pela Defesa, os elementos probatórios amealhados na fase inquisitiva foram secundados por aqueles produzidos na seara judicial, sobretudo pela prova oral e pericial (págs. 66/69 e 168/175), inexistindo dúvidas acerca da presença da autoria e materialidade do delito.

No mais, não há como se acolher a tese da Defesa de desclassificação do crime para a forma tentada.

Isso porque, pela Teoria da Amotio, hoje adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento exarado sob a sistemática de julgados repetitivos, basta a inversão da posse da coisa para consumação do delito patrimonial, sendo indiferente a perseguição da vítima ou a recuperação da coisa.

Tema repetitivo 934: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Em aplicação da teoria, cita-se como exemplo:

“[...] 4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois. 5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante” (STJ. 5ª Turma, HC 618.290/RJ, j. 17/11/2020).

Ainda, pelo Egrégio Tribunal Estadual paulista:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Simples - Art. 155, caput, do CP - RECURSO DEFENSIVO - NÃO DISCUTE O MÉRITO - Autoria e materialidade devidamente comprovados. Pugna pelo reconhecimento do crime de furto em sua forma tentada - IMPOSSIBILIDADE - Nos moldes da teoria da amotio ou apreensão, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1506629-13.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

Portanto, na medida em que os réus foram detidos quando já tinham deixado o pátio com a res furtiva e estavam empreendendo fuga, forçoso reconhecer que, nessas circunstâncias, já tinha ocorrido a inversão da posse, com a consumação do delito. Ainda, as provas coletadas na instrução, são suficientes a demonstrar que a conduta típica foi realizada pelos réus em conjunto, unidos pelo mesmo propósito de êxito na empreitada criminosa.

Por fim, o crime de furto foi praticado por volta das 02h40min, ou seja, durante o repouso noturno, tipificando a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do

Código Penal.

A Doutrina e jurisprudência debatem-se há algum tempo quanto à possibilidade da aplicação da causa de aumento supracitada nas hipóteses de furto qualificado. O principal fundamento daqueles que rechaçam a possibilidade é a topografia do artigo, dado que o § 1º, por óbvio, vem antes do §4º, de modo que não seria possível a aplicação da causa de aumento.

Entretanto, sem embargo de opinião em contrário, não há qualquer óbice à aplicação da causa de aumento, que é realizada apenas na terceira fase do critério trifásico. Aliás, tanto é assim que a doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias admitem a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do §2º do artigo 155 do Código Penal mesmo na hipótese do furto qualificado, mormente quando a qualificadora é de ordem objetiva, conforme já restou assentado no Recurso Especial nº 1.193.194-MG do Superior Tribunal de Justiça, julgado com os rigores do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

Ora, se a posição topográfica não impede o reconhecimento da causa de diminuição, razão não há para que tal fundamento possa impedir a incidência da causa de aumento.

Nesse sentido, no informativo de jurisprudência nº 554, o C. Superior Tribunal de Justiça fez constar que:

"DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. A causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP - que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na forma qualificada (§ 4º) do delito de furto. Isso porque esse entendimento está em consonância, mutatis mutandis, com a posição firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.193.194-MG, no qual se afigurou possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), máxime se presentes os requisitos. Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2º do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o § 1º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico. Cabe registrar que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma do STJ segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput do art. 155). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425-RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2º), também não se considera essa ordem para imposição da causa de aumento (§ 1º)".

(HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014).

Destarte, a condenação pelo crime de furto noturno qualificado é medida que se impõe. Provado o crime imputado, passo doravante à dosimetria da pena.

Com relação ao réu ELIEL ALBERTO FERREIRA

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não possuía maus antecedentes na data dos fatos (págs. 19/20); poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, não são especialmente reprováveis, não autorizando qualquer majoração nessa fase. Assim, fixo a pena no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não existe circunstância agravante. Presentes as atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal – pág. 12) e da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”), que, no entanto, não podem ser sopesadas pela impossibilidade da pena se fixada nessa etapa aquém do mínimo legal (Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). Assim, a pena intermediária se mantém em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento relativa ao repouso noturno, previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Os dias-multa terão valores mínimos legais, devido à ausência de prova da capacidade econômica do réu.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a impossibilidade de fixação de regime mais gravoso exclusivamente com base na gravidade em abstrato do delito (Súmula 440 do STJ), fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena (artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal).